

Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/2005, n. 8875

Massime • 1

La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 cod. civ.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/2005, n. 8875

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 8875

Data del deposito : 28 aprile 2005

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AN GI, titolare della ditta individuata "NUOVA EDIL 2001", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI Simonetta, che lo difende unitamente all'avvocato ENZO CROCE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LI ER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato CEFALY Francesco, che la difende unitamente all'avvocato MAURO BUSSANI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2616/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/10/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/02/05 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso dell'imprenditore edile GI IG il Presidente del

Tribunale di Monza emise, sulla scorta di un'allegata scrittura privata sottoscritta da ER EL, decreto ingiuntivo a carico di quest'ultima per l'importo di L. 20.000.000, oltre accessoria titolo di pagamento del saldo di lavori eseguiti su un immobile dell'intimata.

Con atto notificato in data 17.11.93 la EL propose opposizione, sostenendo che la scrittura del 6.4.93 prodotta dal ricorrente non rappresentava un riconoscimento di debito, ma solo una modificazione dei preventivi in precedenza stilati dall'appaltatore e mai accettati dalla committente, e che peraltro il IG, oltre a non decurtare dalla pretesa di pagamento un convenuto "sconto" del 5% sul valore dell'appalto, aveva inesattamente eseguito le proprie prestazioni, presentando l'opera gravi vizi e difetti;

su tali premesse chiedeva la revoca del decreto opposto ed, in via riconvenzionale, la riduzione del corrispettivo dell'appalto, oltre al risarcimento dei danni. Si costituiva e resisteva l'opposto, sostenendo che la scrittura esponeva un conteggio a saldo, riduttivo delle proprie originarie richieste, essendo stato tra l'altro praticato uno sconto di L. 20.000.000 in ragione dei riconosciuti difetti dell'opera, limitati all'intonaco esterno, e, comunque, eccependo la decadenza della committente dalla garanzia per i vizi. All'esito di istruttoria documentale e testimoniale, il giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata espletata anche consulenza tecnica, veniva definito con sentenza del 23.1.98, di rigetto dell'opposizione, sulla base della ritenuta natura transattiva della scrittura privata del 6.4.93, desunta, "non solo dal contesto della stessa, ma anche sulla scorta del carteggio che l'aveva preceduto, dal comportamento delle parti e dalle modalità e circostanze della redazione (da parte di un commercialista di comune fiducia a conoscenza della vertenza, poi sentito quale teste) dello

scritto. Proposto appello dalla EL, resistito dal IG, con sentenza del 21.3.2001 della Corte d'Appello di Milano, accolto per quanto di ragione il gravame e, per l'effetto, l'opposizione e la domanda riconvenzionale relativa all'azione di riduzione, ed operata la compensazione tra il credito dell'appaltatore di L. 20.000.000 e quello della committente, di L. 20.992.992 (in ragione dei vizi accertati dal c.t.u.) coesistenti alla data del 15.9.93, tenuto conto degli interessi e del pagamento operato dall'opponente in forza del decreto ingiuntivo, il IG veniva condannato al pagamento della somma di L. 23.208.075 in favore dell'appellante, oltre al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio. A tale decisione la corte territoriale è pervenuta sulla scorta delle seguenti essenziali considerazioni:

a) la scrittura in data 6.4.93, come emergeva dal contesto - retroestesa ad un conteggio spedito dalla EL al IG, contemplante sia la riduzione dell'importo di base, sia lo sconto del 5%, oltre agli acconti - e dai chiarimenti testimoniali resi dal suo materiale redattore, commercialista di comune fiducia delle parti, non rappresentava una transazione, ma solo un riepilogo contabile, eseguito "in base ai prezzi unitari del preventivo ed ai lavori svolti, senza alcuna considerazione dei vizi dell'opera", che non vi risultavano contemplati;

b) tale interpretazione dell'atto era confortata anche dal comportamento processuale del IG, il quale, prima "minimizzando i vizi denunciati, e quindi facendo valere la scrittura quale riconoscimento di debito e promessa di pagamento in due rate del corrispettivo riconosciuto per l'opera esente da vizi", avrebbe poi invocato la tesi della transazione "solo a seguito della motivazione della sentenza";

c) la presa in consegna dell'opera e l'effettuazione della contabilità finale dei lavori non poteva comportare, tenuto conto delle già esternate contestazioni, la rinuncia a far valere la garanzia per i vizi palesi dell'operacene poi erano risultati confermati dalla consulenza;

d) lo sconto preteso dalla committente, tuttavia, risultava computato nel conteggio riepilogativo. Avverso tale decisione il IG ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Resiste la EL con controricorso, illustrato con successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce "insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia, e violazione dell'art. 1362 C.C. sull'interpretazione del contratto, lamentando che i giudici di appello, nell'interpretazione della comune volontà dei contraenti e nell'escludere la natura transattiva della scrittura 6.4.93, avrebbero ommesso di tener conto del loro comportamento complessivo, anteriore e successivo alla conclusione del contratto, che era stato invece correttamente e con completezza d'indagine valutato dal Tribunale, così fornendo un giudizio frutto di valutazione illogica e frammentaria degli elementi della vicenda e di travisamento della condotta processuale dell'oppositoci quale avrebbe fin dal primo grado sostenuto, negli scritti difensivi versati in atti, detta

natura dell'atto.

Le censure sono infondate.

Ai sensi dell'art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto;

da tale norma consegue, a termini della costante giurisprudenza di legittimità, la necessità che tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo (tra i quali segnatamente quello, essenziale, della reciprocità delle concessioni), debbano risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni (v. tra le altre, **Cass. sez. 3^a n. 1787/99, n. 5344/00**). Correttamente, pertanto, è stata esclusa nel caso di specie l'invocabilità di una transazione i cui elementi non risultavano tutti desumibili dalla scrittura del 6.4.93, nella quale erano solo contenuti dei conteggi, senza alcuna menzione delle pretese redibitorie avanzate dalla committente, né delle eventuali parziali ammissioni dei vizi, da parte dell'appaltatore, in funzione della riduzione del credito da lui originariamente vantato. Il difetto di prova scritta in ordine all'elemento essenziale dell'aliquo dato et aliquo et aliquo retento, oggettivamente caratterizzante il negozio di cui all'art. 1965 c.c., ha correttamente comportato la riforma della decisione di primo grado, tanto più ove si consideri che nella stessa si era addirittura ritenuto di qualificare la scrittura di cui sopra quale ricognizione di debito o promessa di pagamento, non incorporata nella transazione, ma a questa connessa e conseguente, così indebitamente ponendo a base del relativo accertamento elementi, palesemente extra-testuali di prova testimoniale e presuntiva, in palese violazione della regola probatoria dettata dall'art. 1967 cit.

Di siffatti elementi (che peraltro ultroneamente i giudici di appello hanno ritenuto di utilizzare in funzione rafforzativa della, già testualmente evidente natura meramente ricognitivo - contabile dell'atto), il ricorrente propone la valorizzazione ai fini non della corretta interpretazione del contenuto per sé chiaro, della scrittura in questione, bensì di un'inammissibile integrazione probatoria circa l'assunta natura transattiva della stessa. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. per omessa motivazione e statuizione in ordine alla comprovata eccezione di decadenza della committente dall'actio quanti minoris, che sarebbe "stata proposta in entrambi i gradi" "Esultando" "documentalmente" fondata.

Il motivo è inammissibile, perché, contrariamente a quanto dedotto, l'eccezione, che il Tribunale aveva ritenuto assorbita in considerazione della ritenuta natura transattiva della scrittura del 6.4.93, non risulta riproposta in grado di appello, come rilevasi dall'esame dei relativi atti (comparsa di costituzione e risposta e verbale di precisazione delle conclusioni, nelle quali le richieste sono genericamente limitate al rigetto dell'appello e conferma della sentenza del Tribunale) e dato atto in motivazione dalla Corte territoriale (v. pag. 15, cpv 2 della sentenza di secondo grado), che pertanto lì non era tenuta ad esaminarla, dovendo la non riproposta eccezione considerarsi abbandonata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; tale norma, pur non facendo obbligo alla parte

vittoriosa in primo grado, le cui richieste ed eccezioni subordinate o alternative non abbiano formato oggetto di esame perché ritenute assorbite o per altri motivi, di proporre impugnazione incidentale al riguardose impone tuttavia l'onere dell'espressa riproposizione, al fine di superare la presunzione di rinuncia al riguardo dettata (v., tra le altre e più recenti **Cass. sez. 3^a, n. 18721/03 e 18743/03**, nonché **sez. 2^a, n. 12345/03**, nella quale si è precisato che l'onere in questione esige specifica e precisa indicazione della domanda o eccezione non accolta o rimasta inesaminata, non potendosi ritenere soddisfatto da un mero e generico richiamo alle posizioni

assunte nel grado precedente). Il ricorso va, conclusivamente, respinto, con condanna del soccombente alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro milletrecento, di cui 1.200 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005